

刑法
No153

共通問題 R5-3

(配点: 3)

月	日
月	日

次の【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものを2個選びなさい。

【判 旨】

共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。したがって、このような関係において共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない。さればこの関係において実行行為に直接関与したかどうか、その分担又は役割のいかんは、共犯の刑責自体の成立を左右するものではないと解する。

【記 述】

1. 【判旨】を前提にすると、殺意を有する者と傷害の故意にとどまる者との間で共謀共同正犯が成立する余地はない。
2. 【判旨】は、共同正犯の成立には、実行行為の一部を分担することは必要ないとの立場に立っている。
3. 【判旨】は、共謀共同正犯の成立には、単に関与者の内心における意思の合致があるだけでは十分でなく、客観的な謀議行為が必要であるとする考えと矛盾しない。
4. 【判旨】に対しては、共同正犯を教唆及び幫助と区別することが困難になるとの批判がある。
5. 【判旨】を前提にすると、共謀共同正犯の成立には、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることが必要である。

№153	共謀共同正犯	正答率
共通R5-3	正 解	86%
	1、5 (順不同)	

本問の【判旨】は、最大判昭33.5.28(百選175事件)を題材としたものである。

1 誤っている

罪名従属性における考え方としては、特定の犯罪を数人の関与者が共同して行うこと(数人一罪)を共犯とする犯罪共同説と、数人が行為を共同して各自の犯罪を実現する(数人数罪)のが共犯であるとする行為共同説とがある。行為共同説によれば、共犯は行為・因果関係を共同にすればよいのであって、犯罪を共同にする必要はないことから、異なる罪名についても共犯が成立し得るが、犯罪共同説については、更に、共犯の従属性を徹底して、共犯は罪名を共同にする範囲でしか成立しないとする完全犯罪共同説と、異なる罪名であっても、構成要件的に重なり合う限度では共犯の成立を肯定し得るとする部分的犯罪共同説とに分かれる。【判旨】を見ると、「共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない」と述べるだけで、これだけでは完全犯罪共同説を採っているとは言いが切れない。よって、【判旨】を前提にすると、殺意を有する者(殺人罪)と傷害の故意にとどまる者(傷害致死罪)との間で共謀共同正犯が成立する余地はないとはいえない。したがって、本記述は誤っている。なお、判例(最決平17.7.4、百選16事件等)・通説は、部分的犯罪共同説の立場に立っている。

2 正しい

60条は、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と規定しているが、同条の解釈としては、「犯罪を実行した者」という文言を重視して、実行行為の一部を分担した者だけが共同正犯であるとする実行共同正犯論と、「共同して」という文言を重視して、犯罪の実行以外の共謀や準備にのみ関与した者も共同正犯になり得るとする共謀共同正犯論とが対立してきた。学説では、従来、実行共同正犯論が支配的であったが、現在では、共謀共同正犯論を肯定する見解が主流となっている。判例は、現在に至るまで一貫して共謀共同正犯を肯定している。【判旨】も、「直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない」として、共同正犯の成立に実行行為の分担が必要とはしていない。よって、【判旨】は、共同正犯の成立には、実行行為の一部を分担することは必要ないとの立場に立っているといえる。したがって、本記述は正しい。

3 正しい

共謀共同正犯の成立要件である「共謀」をどう捉えるかについては、共謀を「共同犯行の認識」あるいは「意思連絡」という主観的な状態と解する主観的謀議説と、そのような主観的な状態だけではならず、客観的な謀議行為への参加が必要であるとする客観的謀議説とがある。【判旨】を見ると、「共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議」が必要である旨を述べているが、これだけではどちらの説に立っているのか明らかではない。なお、【判旨】の題材である最大判昭33.5.28に対しては、実行行為に関与しない共同者についても共同正犯としての責任を負わせるためには、単なる主観的な要件に止まるものではなく、実行共同正犯における客観的な要件である「実行行為の分担」にも比すべきものが必要であることから、同判例は、客観的な謀議行為の存在が必要であることを示しているとの説明がなされている。よって、【判旨】は、客観的な謀議行為が必要であるとする考えと矛盾しない。したがって、本記述は正しい。もっ

とも、最高裁は、いわゆるスワット事件（最決平 15.5.1、百選 I 76 事件）において、謀議行為に参加していない者にも共謀共同正犯を認めたことから、主観的謀議説に立っているという見解もある。

4 正しい

【判旨】を見ると、共謀共同正犯論を肯定して、「直接実行行為に関与しない者でも」共同正犯が成立し得るとしている。【判旨】のように、直接実行行為に関与しない者についても共同正犯の成立を認めると、共同正犯と狭義の共犯（教唆及び幫助）の区別基準として、犯罪の実行行為に関与したか否かという基準によることができなくなり、両者の区別が困難になると批判されている。よって、【判旨】に対しては、共同正犯を教唆及び幫助と区別することが困難になるとの批判があるといえる。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

【判旨】を見ると、「共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない」とした上で、「この関係において実行行為に直接関与したかどうか、その分担又は役割のいかんは、共犯の刑責自体の成立を左右するものではない」と述べるだけで、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることが共謀共同正犯の成立に必要な要件であるとはしていない。よって、【判旨】を前提にすると、共謀共同正犯の成立には、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることが必要であるとはいえない。したがって、本記述は誤っている。なお、実行行為を行わない者と実行行為者との間の指揮命令関係が問題となったのは、いわゆるスワット事件（最決平 15.5.1、百選 I 76 事件）においてであり、正犯性を基礎づける一事情として指揮命令関係の存在が挙げられている。

以上により、誤っている記述は 1 と 5 であり、したがって、正解は肢 1 と肢 5（順不同）となる。